

1502232-54.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... usuários e movimenta todo o esquema de narcotráfico, que é responsável por uma enorme cadeia de outros crimes, como tráfico de armas, roubos, furtos, homicídios, formação de quadrilha etc, vitimando, com sua conduta, toda sociedade.

Não se ignora o reconhecimento, no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal, de Repercussão Geral quanto ao tema (RE 635.659/SP), contudo, o julgamento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502232-54.2020.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 09 de março de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr.

FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Nathalie Cristina Cardoso, Assistente Judiciário, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502232-54.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2176953/2020 - 4º

Distrito Policial de Santos, 12526966 - 4º Distrito Policial de Santos, 332/20/214

- 4º Distrito Policial de Santos, 2176953 - 4º Distrito Policial de Santos,

2176953/2020 - 4º Distrito Policial de Santos, 2176953 - 04º D.P. SANTOS,

332/20/214 - 04º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO ALEXANDRE SANTOS SILVA

Vistos.

IAGO ALEXANDRESANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Lei Antidrogas, porque na manhã de 20 de julho de 2020, na Rua São Francisco, próximo ao número 340, Centro, em Santos, trazia consigo 5 (cinco) porções contendo 8g de "cocaína" e

2 (duas) pedras de "crack", pesando 1g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (págs. 64/66).

O réu foi preso em flagrante (págs. 01/21).

Folha de antecedentes criminais (págs. 22/24 e 136/137).

Foi concedida a liberdade provisória (págs. 43/47).

Laudo pericial (págs. 85/87 e 88/90).

Notificado (pág. 77), o réu apresentou defesa preliminar (págs. 91/97), tendo a denúncia sido recebida em 31 de agosto de 2021 (págs. 108/110).

O réu não foi localizado no endereço fornecido para intimação da audiência de instrução (pág. 130).

Na audiência de instrução foi decretada a revelia do réu e ouvidas duas testemunhas de acusação. Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (págs. 138/140).

É o relatório necessário.

À fundamentação e decisão.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, que vem assim previsto na Lei nº 11.343/2006:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Consigno, inicialmente, que "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 04, pelo auto de constatação preliminar de pág. 07 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de págs. 85/87 (repetido a págs. 88/90).

A autoria restou igualmente demonstrada pela prova documental e oral coligida aos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante e termo de interrogatório do réu (pág. 10), que, na fase policial, confirmou portar as drogas apreendidas, sustentando, porém, que o fazia para uso próprio.

Ademais, as testemunhas da acusação, Michel Rodrigues da Silva e Kaio Ferreira da Silva Kurashiki, Policiais Militares, disseram em Juízo, em suma, que estavam em patrulhamento quando abordaram o réu em um ponto conhecido como área de tráfico de droga e encontraram com ele os entorpecentes apreendidos. Na abordagem o réu afirmou que buscava drogas ali para revender, mas não presenciaram ato de venda.

A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Reforçando a relevância da palavra dos policiais:

"Entorpecente - Insuficiência de provas - Não ocorrência - Absolvição -

Impossibilidade - Conjunto probatório seguro que demonstra a prática do delito de tráfico. Prova - Palavras dos policiais - Validade - Inexistência de motivos para incriminar o réu injustamente. Causa de aumento de pena - Artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 - Caracterização - Delito cometido no interior do presídio - Apelação do réu não provida.x (TJSP, Apelação 990092195549, 16ª Câmara de Direito

Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010) (grifei).

“PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório seguro e coeso Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Prova segura - Condenação mantida - Reincidência não verificada - Réu tecnicamente primário - Substituição da pena por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Réu que praticou novo delito durante o livramento condicional - Alteração do regime para o aberto permitida - Recurso parcialmente provido para esse fim (voto 8006). (TJSP, Apelação 990081609592, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010) (grifei).

Não é demais dizer que o réu foi preso em flagrante, fato que, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: “Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

A pretensão punitiva, à vista desse cenário probatório, é procedente apenas em parte, como já anunciado, porquanto, na espécie, há que se aplicar o artigo 383 do Código de Processo Penal, que diz: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”, para a desclassificação do artigo 33 para o delito do artigo 28 da Lei Antidrogas, que tem a seguinte redação:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

A desclassificação é necessária porque a denúncia de que o réu traficava drogas não se confirmou.

Com efeito, em solo policial o acusado sustentou que a droga com ele encontrada se destinava ao consumo próprio e, ao meu sentir, tal versão não foi afastada pelas provas entabuladas neste processo.

Isso porque, como se viu nos depoimentos prestados pelos policiais, não foi presenciada nenhuma atividade de comércio. Além disso, a quantidade de droga encontrada em poder do acusado era pequena.

Note-se que os artigos 28 e 33 da Lei de Drogas possuem os mesmos verbos-núcleos citados na inicial acusatória e, nos termos do §2º do mesmo artigo 28 e pelas

provas que foram coligidas aos autos, há que se concluir pela subsunção da conduta do réu ao caput do artigo 28 em questão, eis que o réu confirmou ser usuário da substância apreendida, a quantidade de entorpecentes era pequena e os policiais não presenciaram terceiros se dirigindo ao acusado para fins de aquisição de entorpecente.

Ora, prevalece, in casu, o princípio do in dubio pro reo, com o fito de dar maior valor à versão apresentada pelo denunciado em solo policial, à vista da frágil prova coletada.

Por fim, importa assentar a constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pois tutela, em verdade, não só o usuário, mas, sim, toda a coletividade, a saúde pública como um todo, não podendo o Estado quedar-se inerte diante desta desestabilização social.

Respeitam-se, pois, os princípios da ofensividade e da alteridade, na medida em que o usuário, ao consumir a droga ou tê-la a tanto, serve de alimentador e instigador de novos usuários e movimenta todo o esquema de narcotráfico, que é responsável por uma enorme cadeia de outros crimes, como tráfico de armas, roubos, furtos, homicídios, formação de quadrilha etc, vitimando, com sua conduta, toda sociedade. Não se ignora o reconhecimento, no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal, de Repercussão Geral quanto ao tema (RE 635.659/SP), contudo, o julgamento do mérito da matéria já se iniciou, mas ainda não encerrou.

Dessa forma, como tal julgamento não foi concluído, é certo que, no momento, a regra contida no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 mantém-se incólume e vigente no ordenamento jurídico, tal como tem sido, até o presente, reiteradamente reconhecido.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. CONDUTA TÍPICA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESPROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator ((HC n. 453.437/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/2018; HC 478.757/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 11/2/2019). (...)) (HC 535.785/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) (grifei).

Nesse mesmo sentido, inclusive, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - Posse ou porte de drogas para uso pessoal - Artigo 28 da Lei de Drogas. 1. PRELIMINAR - Inconstitucionalidade do referido artigo - Não cabimento - Precedentes - Devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da criminalização da posse ou porte de drogas para uso próprio - PRELIMINAR REJEITADA 2. MÉRITO - Absolvição por atipicidade da conduta - Inadmissibilidade - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Prestação de serviços à comunidade - Adequada à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1515307-96.2019.8.26.0019; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021)

De se mencionar, em reforço à constitucionalidade do delito pelo qual o réu se vê processado, a não-caracterização do princípio da insignificância.

De fato, a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico protegido, pois é inidônea a inserção em tipos penais incriminadores de condutas inofensivas ou incapazes de lesar o interesse juridicamente protegido, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e não observância do próprio conteúdo material do axioma da legalidade penal.

Entretanto, no presente caso, deve-se considerar que há a finalidade preventiva genérica e repressiva do direito penal, que não pode emular condutas criminosas em qualquer organização social, seja por mecanismos de atipicidade ou por presumida e abstrata ausência de imputação objetiva do nexo causal.

O delito de uso de substância entorpecente, como mencionado alhures, afeta bem jurídico de proteção da saúde ou incolumidade pública, sendo o dolo de perigo abstrato, não existindo incidência do princípio da insignificância ou descriminalização da conduta em face do princípio da alteridade penal.

A tese da insignificância também é afastada veementemente pela jurisprudência pacífica da Corte Superior: "Esta Corte firmou o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), porquanto se trata de delito de perigo abstrato, e a pequena quantidade de entorpecente é inerente à própria essência do tipo penal em questão. Precedentes" (RHC 77554/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 13/12/2016, v.u.).

De rigor, pois, a condenação no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e, em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui notórios maus antecedentes (págs. 136/137); poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do delito é identificável pelo desejo de usar substância proibida, o que já é punido pelo próprio tipo; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, não tendo a se valorar, sendo que as consequências do delito são desconhecidas; a quantidade e a natureza da droga apreendida não justificam qualquer exasperação.

Inexiste agravante ou atenuante a ser considerada, tampouco causas de aumento.

Assim, tendo em vista ser o réu primário e sem circunstâncias judiciais desabonadoras, a pena a ser aplicada é aquela prevista pelo artigo 28, inciso I, da Lei de Tóxicos (11.343/06), motivo pelo qual fixo em seu desfavor a pena de advertência.

Dispositivo:

Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para condenar o réu IAGO ALEXANDRE SANTOS SILVA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 28 da lei 11.343/2006 - Lei Antidrogas, à pena de advertência, na forma prevista no inciso I do sobredito artigo.

Encaminhe-se o entorpecente para incineração, se ainda não providenciada.

Liberem-se os valores em dinheiro apreendidos ao sentenciado, eis que não confirmadas como sendo produto de tráfico.

Taxa judiciária devida na forma do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/2003, observadas as regras da Lei nº 1.060/1950, se o caso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, cumprindo as demais formalidades legais.

P.I.C.

Santos, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA